



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 217/11

התובעים:

משה כובאני ואח'

ע"י ב"כ עו"ד מ. חגי

רח' מונטיפיורי 6/8, אשדוד

- נ ג ד -

הנתבעים:

ישראל לוין ואח'

ע"י ב"כ עו"ד מ. היילברון

רח' בן יהודה 1, ירושלים

פ ס ק – ד י נ

עניינה של התביעה - דרישת התובעים ליתן כנגד הנתבעים צו מניעה קבוע האוסר עליהם או על מי מטעמם לבצע כל פעולת בניה והריסה ברכוש המשותף בבית המשותף בגוש 30079 חלקה 111 ברחוב ירמיהו 14 בירושלים (להלן: "הבית או הבית המשותף"), ללא הסכמת התובעים.

א. העובדות הנדרשות לעניין:

1. המדובר בבית המשותף בגוש 30079 חלקה 111 בירושלים. בבית המשותף, כך על פי נסח הרישום, קיימות 11 תתי חלקות. על פי צו הבית המשותף, תתי חלקות 1-2 הוגדרו כ"מחסן", ואילו יתר תתי החלקות הוגדרו כ"דירות".



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

2. התובעים הינם בעלי הזכויות בתתי חלקות 2,8,11. על פי הרש וס כיום בפנקס הבתים המשותפים, שטח דירות יהם מגיע לסך של 127 מ"ר, כאשר חלקם המצטבר ברכוש המשותף הינו 127/532. התובעים רכשו את דירה מס' 8 בשנת 2005, דירה מס' 2 [להלן: "המחסן"] בשנת 2008, ודירה מס' 11 עוד בשנת 1986.
3. הנתבעים הינם בעלי זכויות בתתי חלקות 3,6,9 בבית המשותף. שטח דירותיהם מגיע לסך של 126 מ"ר, וחלקם הכולל ברכוש המשותף הינו 126/532.
4. בבית המשותף רשומות 5 תתי חלקות נוספות אשר בעלי הזכויות בהן לא צורפו לתובענה.
5. הנתבעים הגישו בקשה להיתר לתוספות בניה בעמודה אחת, בהתאם לתכנית 8182 [אשר פורסמה למתן תוקף ביום 27.2.03] המאפשרת תוספת בניה של 283 מ"ר שטח עיקרי. במסגרת בקשתם בקשו הנתבעים גם הקלה מקו בניין לצורך בנית ממ"ד.
6. התובעים התנגדו לבקשה.
7. בהחלטת ועדת הערר לתכנון ובניה – מחוז ירושלים, קבעה ועדת הערר כי ה בקשה להיתר, למעט דרישת ההקלה, תואמת תכנית, ולכן מן הדין לאשרה. אשר לדרישה להקלה מקו בניין, קבעה ועדת הערר כי אין פגיעה, ולו מינימאלית, בתובעים, ובהתחשב בכך שמדובר בבקשה לצורך בניית ממ"ד, יש לאשרה. הוועדה דחתה, על כן את התנגדות התובעים, תוך שהבהירה כי דחייתה הינה בפן התכנוני בלבד. בנושא הקנייני, הבהירה ועדת הערר, כי יש לפנות לערכאה המוסמכת.
8. ביום 3.11.11 פנו התובעים לבית משפט השלום בירושלים ודרשו כי בית המשפט יורה על מתן צו מניעה זמני.
9. ביום 13.11.11 קבע בית המשפט השלום כי למפקח על רישום המקרקעין סמכות ייחודית לדון בתובענה, ועל כן העביר התובענה לדיון בפניי.
01. ביום 21.11.11 התקיים דיון בסעד הזמני במעמד הצדדים, במסגרתו נשמעו עדי הצדדים, ולאחריו הגישו הצדדים סיכומיהם בכתב.
11. ביום 29.12.11 ניתן צו מניעה זמני, אשר צומצם לאחר מכן, ביום 12.2.12, באופן שהוא לא יחול על בניית הממ"ד, כפי שהוצג בתשריט מש/1.
21. ביום 5.3.12 נשמעו עדי הצדדים לגופו של עניין, ולאחר מכן ס יכמו הצדדים טיעוניהם בכתב.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ב. טענות התובעים בקצרה:

31. התובעים טוענים כי נוכח הוראות סעיף 71 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: **"החוק"**), הרי שעל הנתבעים לקבל הסכמת 75% מבעלי הדירות לבנייה המבוקשת על ידם. לטענתם, הנתבעים לא הציגו הסכמות של מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות, שכן התובעים עצמם מחזיקים בשלוש מתוך 11 דירות.
41. לטענת התובעים, אין לקבל את טענת הנתבעים שלפיה אין להביא בחשבון את תת חלקה מס' 2 - המחסן, שכן מדובר בדירה רשומה. רישום זה ביחס לתת חלקה 2 שריר וקיים, ומהווה ראיה חותכת לקיומה של הדירה. ממילא יש לראות את דירה מס' 2 כ"דירה" לכל דבר ועניין.
51. התובעים מוסיפים, כי הנתבעים לא הוכיחו כלל את טענתם כי על המחסן קיים צו הריסה, ומדגישים כי במסמכים שצורפו מטעמם לא הוזכר "צו הריסה" כלל. כן מפנים התובעים לסעיפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, וכן לפסיקה שונה, הקובעים כי רישום צו ההריסה הינו חובה שבדין כדי להגן על זכויות צד ג', אך אין בו כדי למנוע רישום עסקאות בכפוף להערה בדבר צו ההריסה. בהקשר לכך מוסיפים התובעים גם, כי המחסן נבנה בשנת 1961-2, ומאז ועד היום הועברו בו הזכויות, כאשר לאורך כל התקופה לא נרשמה הערה כלשהי בנוגע לצו הריסה. התובעים מפנים בעניין זה לעדותה של הגב' חטבי שלא הסבירה מדוע לא נרשמה הערה בעניין צו הריסה ומדוע עד היום לא ננקטה פעולה כלשהי כנגד המחסן.
61. התובעים סבורים כי יש ליתן משקל זהה למחסן ולדירה, ומפנים לקביעותי במסגרת ההחלטה בבקשה לסעד הזמני. עוד מוסיפים התובעים בעניין זה, כי הנתבעים טוענים טענות סותרות, כאשר מחד גיסא טוענים הם כי אין ליתן משקל למחסן, ומאידך גיסא מביאים דירה כזו [דירה 1 - בה מתגורר ים ה"ה דהן] במניין בעלי הזכויות שהסכימו לבקשתם.
71. אשר לתת חלקה 8 - התובעים טוענים כי לא ניתנה הסכמת בעלי דירה זו בעבר, ואף אם ניתנה הסכמה על ידי בעליה הקודמים של דירה מס' 8, אשר מכרו את הדירה לתובעים, היא אינה מחייבת אותם, שכן הם לא ידעו ולא היו יכולים לדעת אודותיה. בעניין זה מפנים התובעים לכך שלא הוצג רישום כלשהו, הערת אזהרה או רישום בספר החלטות, בדבר ההסכמה הנטענת. כן מפנים התובעים לעדותה של הגב' מונסה [אשר מכרה להם את הדירה מכח היותה יורשת יחד עם אחיה], וטוענים כי עדותה מלאה בסתירות, ומכל מקום ניתן להסיק ממנה כי היא לא העניקה הסכמתה לבניה, ואף אם עשתה כך, הרי שהתובעים לא יכלו לדעת על כך. התובעים מפנים גם לכך שגב' מונסה העידה כי היא



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

היתה רק יורשת אחת מבין כל האחים שירשו את דירה מס' 8, ולא הוצג כל ייפוי כח מטעם האחים האחרים.

81. התובעים טוענים כי בעדותו של מר לוברבוים [אשר מכר את הדירה לנתבעים מס' 1 - לוין] התגלו סתירות מרובות, ולפיכך לא ניתן ללמוד דבר מעדויותיו. כן טוענים הנתבעים כי מכלול הראיות מורה כי בעת מכירת הדירה מלוברבוים ים ללוין, היה ברור שטרם התקבלו ההסכמות הנדרשות על פי סעיף 71 לחוק. לטענת התובעים לוברבוים אף יצר מצג שווא בפני הנתבעים כאילו יש הסכמה של הרוב הדרוש לבני ה המבוקשת, וכעת הוא מנסה לסייע לנתבעים כדי לפתור את הבעיה שנוצרה כתוצאה מהתחייבויותיו ללוין [ר' עמוד 8 שורה 37 לפרוטוקול]. התובעים אף טוענים כי למר לוברבוים סכסוך ארוך שנים עם התובע, ועתה הוא מנסה לפגוע בו באמצעות סיוע לנתבעים.
91. מוסיפים התובעים וטוענים, כי אין ליתן משקל להסכמות חלק מבעלי הדירות משנת 2009, שכן לא על בסיסן התקבל היתר הבניה. התובעים אף מוסיפים כי חלק ניכר מבעלי הזכויות בדירות לא חתומים על כתב ההסכמה משנת 2009. כן טוענים התובעים, כי קיים חוסר וודאות בדבר חתימת הבעלים של דירה מס' 5, דירת הברפלד, בשל הטענות השונות בעניין הירושה. מכל מקום, כך לטענת התובעים, גם כיום חסרה חתימתה של הגב' אלנקרי מרים, שהינה בעלת מחצית מהזכויות בדירה מס' 9.
02. לאור כל זאת, כך טוענים התובעים, אין ספק כי כיום, ועל אחת כמה וכמה בעת הגשת הבקשה להיתר, לא היה בידי הנתבעים הסכמתם של מי שבבעלותם 75% מהדירות אשר שני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, וממילא דינה של התביעה להתקבל.
12. התובעים מוסיפים, כי הנתבעים מנצלים אחוזי בניה בשיעור של 255 מ"ר, מתוך 283 מ"ר שאושרו בסך הכל, ובכך פגיעה אנושה בקניינם של התובעים. בהקשר לכך מפנים התובעים לעדותו של מר לוין בעמוד 9 שורות 30-31 לפרוטוקול, אשר אף הודה, לטענתם, בכך שהוא מבקש לנצל שטח של לפחות 214 מ"ר.
22. לטענת התובעים העובדה כי קיים היתר בניה אינו מלמד דבר לעניין הזכות הקניינית, ומפנים בעניין זה לפסק הדין בת "א (ת"א) 1589/97 הולצמן נ' ארזי [פורסם באתר נבו], ולדברי פרופ' דויטש [מ. דויטש, דיני קניין, חלק א, 695].
32. התובעים מוסיפים, כי הבניה המוצעת אף תגרום לפגיעה קשה לתשתיות הבית המשותף, ותיצור עומס בלתי סביר בבית המשותף.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

42. כן מוסיפים התובעים, כי המבקש הינו רב קהילה, אשר מרכז חייו מצוי סמוך לבית המשותף, ועל כן, כך לטענת התובעים, לא ניתן להביא ו למצב בו יאלץ להעתיק מגוריו לדירה אחרת, עקב מגבלות בניה שייווצרו כתוצאה מבניית הנתבעים.

ג. טענות הנתבעים בקצרה:

52. טענת הנתבעים העקרונית הינה, כי באמתחתם הרוב הדרוש, קרי, הסכמת 75% מבעלי הדירות בבית המשותף, אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

62. הנתבעים טוענים, כי אין ליתן כל משקל למחסן –דירה 2. לטענתם לא התקבל היתר בניה למחסן, ולפיכך לא היה מקום לרושמו כלל. על אחת כמה וכמה, כך טוענים הנתבעים, אין כל אפשרות להביא את המחסן במניין הדירות, מאחר שכנגד המחסן תלוי ועומד צו הריסה. הבאת המחסן במקרה כזה בחשבון, תגרום, כך לטענת הנתבעים, לפגיעה קשה בשלטון החוק ובכללי המינהל התקין. בהקשר לכך מפנים הנתבעים לעדותה של עובדת הציבור, הגב' רות חטבי, בוחנת רישוי בכירה במחלקת מהנדס העיר בעיריית ירושלים, שהעידה כי: "...כתב האישום שהוגש כנגד הקבלן בבית הנמצא בגוש 30079 חלקה 111 לפיו נבנו שטחים שלא בהתאם להיתר לרבות מחסן המצוי בקומת מרתף בשטח המיועד למילוי וניתן צו להריסתו " [ר' תע"צ מיום 1.3.12]. הנתבעים מפנים גם לכך שבגזר הדין מושא כתב האישום הנ"ל נקבע במפורש שיש לאטום את המחסן, וטוענים כי זוהי הוראה הזוהה למעשה לצו הריסה. הנתבעים מדגישים כי נוכח האמור בכתב האישום ובתשריט שצורף אליו, ברור כי גזר הדין מתייחס לחלקה 111, היא החלקה דנן.

72. עוד טוענים הנתבעים, כי לכל היותר, ניתן לראות במחסן חלק מדירת התובעים, שכן בהיעדר היתר בניה למחסן, לא היה ניתן לרשום אותו כיחידה עצמאית נפרדת. יתרה מכך, כך טוענים הנתבעים, הוכח שבפועל המחסן הינו חלק מדירת התובעים, ומפנים לדברי העד בעדותו כמו גם לסעיף 11 לתצהירו של מר לוי. לאור זאת, כך לטענתם, אין להביא בחשבון במסגרת בחינת הרוב הדרוש את המחסן – תת חלקה 2.

82. הנתבעים מוסיפים, כי על אף שמדובר במקרקעין מוסדרים, אין ליתן משקל כלשהו למחסן, שכן רישומו הושג במרמה. במקרה זה, כך לטענתם, יש גם מקום לביטול הרישום, בהתאם לסעיף 125 (א) סיפא לחוק. עוד טוענים הנתבעים כי לו היו התובעים בודקים את הנושא במחלקה הרלוונטית, היו למדים כי כנגד המחסן ישנו צו הריסה, ומשלא עשו כן, אין להם להלין אלא על עצמם. הנתבעים מפנים בהקשר זה להלכות הרבות שהבהירו כי אין להכשיר עבירות בניה, גם מקום בו מדובר בזכויות שנרשמו



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

ונסחרו. לטענתם, אמנם ידוע כי קיימת הפרדה בין דיני התכנון והבניה לבין ההיבט הקנייני, ואולם מדיניות ציבורית ראויה מחייבת את המסקנה שלפיה כאשר קיים צו הריסה לא ניתן לראות בדירה כדירה קיימת וליצור זכויות "יש מאין". הדבר דומה, כך לטענת הנתבעים, לבעל דירה אשר ללא הסכמה וללא היתר, פיצל את דירתו למספר דירות, וטוען להיותו בעל זכות הצבעה כמספר הדירות שפוצלו, וכן דומה הדבר לאדם שהרחיב את דירתו ללא הסכמה וללא היתר, וטוען לבעלות על חלקים ברכוש המשותף בהתאם לגודל דירתו המורחבת. לטענת הנתבעים דוגמאות אלו מורות בבירור כי מי שבנה ללא היתר אינו זכאי ליהנות מפרי חטאיו, ולשיטתם מתן זכות הצבעה לבעלי המחסן שנבנה ללא היתר מגיעה לכדי "פגיעה באושיות החוק ובסדרי שלטון ראויים".

92. מוסיפים הנתבעים כי מכל מקום, במסגרת בחינת ההסכמות לפי סעיף 71 לחוק אין ליתן קול זהה למי שבבעלותו מחסן ולמי שבבעלותו דירה, שכן בעל זכות במחסן, אינו "בעל דירה" לצורך מתן הסכמה להרחבת דירה. לפיכך, ומאחר שלטענת הנתבעים אין להביא בחשבון את שני המחסנים, (ועל אחת כמה וכמה שאין להביא בחשבון את מחסן התובעים בהיותו ללא היתר), הרי שבידם רוב של 7 מתוך 9 מבעלי הדירות, קרי, למעלה מ-75%.

03. הנתבעים טוענים עוד, כי אף אם יכללו אותם שני מחסנים במניין הדירות, הרי שמכל מקום ניתנה הסכמתם של 9 מתוך 11 בעלי דירות. בהקשר לכך טוענים הנתבעים כי נכון להיום הוצגו חתימותיהם של בעלי הזכויות ב-8 דירות וכן במחסן, תת חלקה 1 [דירת דהן], ומפנים לעדויות ולמסמכים שהוצגו בהליך. אשר לדירת הברפלד, מסבירים הנתבעים כי עם הבנתם שצו הירושה חילק את הדירה בין מר הברפלד לילדיו, הוחתמו כל בעלי הזכויות בדירה. ביחס לחתימתה של הגב' אלנקרי, טוענים הנתבעים כי חתימת בעלה היתה גם בשמה, ומכל מקום, אין צורך להוכיח חתימתה של הגב' מרים אלנקרי, שכן היא עצמה ממבקשי ההיתר מושא התובענה והיא אף נתבעת בתיק דנן.

13. גם ביחס לדירה 8 טוענים הנתבעים, כי הבעלים הקודמים של דירה מס' 8, נתנו הסכמתם לבניה המבוקשת בעבר, והתובעים ידעו על הסכמה זו, ועל כי הנתבעים מסתמכים עליה. לטענת הנתבעים בנסיבות אלו הסכמה זו מחייבת את התובעים אף על פי שלא נרשמה בספר ההחלטות של הבית המשותף.

23. התובעים מפנים בעניין זה לעדותה של הגב' מונסה, אחת מבעלי הזכויות בדירה 8 בעבר, אשר העידה כי היא זו שטפלה בדירה מס' 8 בשם כל בעלי הזכויות, ונתנה הסכמתה לבניה המבוקשת בשמה ובשם יתר היורשים. הנתבעים טוענים בהקשר לכך, כי התובע ידע על כי גב' מונסה נתנה הסכמתה לבניה. הנתבעים מפנים בעניין זה לעדות התובע



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בעמוד 4 שורות 13-14 לפרוטוקול בבקשה לצו המניעה הזמני, ולכך שבתצהיר התובע לא צוין כי הוא לא ידע על ההסכמה, על אף שנושא זה הועלה על ידי הנתבעים בשלב הדיון בסעד הזמני. כן מפנים הנתבעים לתצהיריהם מהם עלה כי התובע ידע על הסכמתה של הגב' מונסה להרחבת המבוקשת, בטרם רכש דירתה.

33. עוד טוענים הנתבעים, כי העובדה שתכנית 8182 אושרה לאחר שהתקבלו הסכמותיהם של 9 מתוך 11 בעלי דירות, מוכיחה כי אכן גב' מונסה הסכימה לתכנית וכי כל מי שהיה מעורב בדבר, ובכלל זה התובעים, ידע על כך. כן מפנים הנתבעים לפרוטוקול הוועדה המחוזית שדנה בתכנית, ממנו עולה כי ההתנגדות לתכנית הוגשה בשם שתי דירות בבית המשותף, ולא הועלתה טענה כלשהי בדבר הרוב הדרוש. לטענת הנתבעים בכך הוכחה ניצחת לכך שהתובעים, אשר היו בעלי דירות בבית המשותף במועד הרלוונטי, ידעו כי קיימת הסכמה של 9 דירות, ובכלל זה של בעלי הזכויות בדירה מס' 8. לטענת הנתבעים רק לאחר שרכשו התובעים את דירה 8 הם חליטו להעלות טענה זו. הנתבעים אף שוללים מכל וכל את ניסיון התובעים להטיל דופי באמינותם של העדים לוברבוים ומונסה.

43. הנתבעים מוסיפים, כי התנהלות התובעים נגועה בחוסר תום לב רב עד מאוד המצדיק התעלמות מעמדתם, בהתאם להלכות השונות שנקבעו בעניין זה. הנתבעים טוענים כי התובעים עצמם סגרו וקרו מרפסות בשטח של 13 מ"ר ללא היתר כדין, ובנו מחסן בחצר. כן טוענים הנתבעים כי התובעים מתעמרים בהם ומוליכים אותם שולל לאורך כל הדרך, על אף שהם היו נכונים לויתורים מרחיקי לכת.

53. לאור כל המוסבר, סבורים הנתבעים כי יש לסלק התביעה על הסף ולחייב את התובעי ם בהוצאות המשקפות את חוסר תום לבם.

ד. דיון והכרעה:

63. סעיף 71ב' לחוק קובע כי:

"על אף הוראות סעיף 62(ב) סיפה...רשאים מי שבבעלו תם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה..."



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

73. מהוראתו הברורה של סעיף 71ב' עולה, כי ככלל על מנת שהנתבעים יהיו רשאים להרחיב דירתם על הרכוש המשותף, עליהם לקבל הסכמת 75% מבעלי הדירות בבית המשותף, אשר שני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.¹

83. בתיק דנן עולות שאלות מעניינות ביותר, החולשות על דיני הקניין, על דיני התכנון והבניה, ועל היחס ביניהם, בכל הנוגע לפרשנותו של סעיף 71ב' הנ"ל. אולם, במקרה שלפנינו, כפי שיורחב להלן, הוכח בפני באופן חד משמעי, כי לנתבעים הסכמות של 9 מתוך 11 דירות בבית המשותף, ועל כן, בשלב זה אין צורך שאכריע בכל השאלות שבמחלוקת, וניתן להשאירן בצריך עיון.

93. כפי שנקבע לא אחת, הסכמה להרחבה אינה חייבת להינתן באסיפה הכללית, ובעל דירה רשאי להחתים את יתר בעלי הדירות באופן פרטני [ר': ע"א 1415/00, אברהם נ' אזרד (לא פורסם); ת"א (שלום-י-ם) 2998/04 כולל אברכים מצוינים נ' אבנצור חביב אורי, תק-של 1595, 1596 (2005); ת"א (שלום-י-ם) 14565/06 משה שמחוביץ ואח' נ' שפרה גיל ואח' (פורסם באתר נבו); בש"א (שלום-י-ם) 8251/07, שטיין נ' קוצר (פורסם באתר נבו); ר' גם: א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, 217].

04. כן נקבע, כי הסכמה זו יכולה להינתן בכל עת, אף לאחר שההרחבה כבר בוצעה, ולא יהא מקום למתן צו האוסר שימוש בהרחבה [מהפן הקנייני כמובן], אם יוכיח בעל הדירה כי בידיו ההסכמות הנדרשות. יפים לעניין זה דברי פרופ' דויטש [מ. דויטש, קניין, 698-699], שקבע כדלקמן:

...בעניין שנדון בבית משפט השלום בעניין שטנג נפסק, כי תיקון מס' 18 לחוק, אין בכוחו להכשיר פעולה שנעשתה שלא כדין בעבר, באמצעות קבלת החלטה עתה ברוב המיוחד, לפי התיקון. עם זאת נקבע, כי אין טעם לחייב עתה בהשבת מצב לקדמות, כאשר ברור שקיים רוב בעד ההצמדה לפי תיקון 18 לחוק...אולם באשר לצו מניעה, בהיותו חוזה פני עתיד בלבד, אין אכן הצדקה לגרום להריסה מי ותרת, כאשר בעלי רוב החלקים החליטו עתה להכשיר את הפעולה, והיא ניתנת, אם כן לבצוע חוזר. הריסה כאמור גם תעמוד בניגוד לתורה הכלכלית- תועלתית. הדין

¹ יוער, כי במסגרת סעיף 71ב' נקבע כי לשם הר חבה שמטרתה בניית ממ "ד, די ברוב של 60 אחוזים מבעלי הדירות. במקרה דנן בראשית הד רך היו חלוקים הצדדים גם בעניין ההרחבה לשם בניית ממ "ד, ואולם, בסיכומיהם זנחו התובעים נושא זה [ור' גם החלטתי בבקשה לצמצום צו מניעה מיום 12.2.12]. מכל מקום, לאור החלטתי להלן אין צורך להידרש לכך.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בסוגיה זו מקביל לדין החל כאשר מתקבלת החלטה בדיעבד של האסיפה הכללית, המכשירה פעולה שפוגעת ברכוש המשותף, בעוד שסעיף 2(א) לתקנון המצוי דורש כי החלטה המכשירה פגיעה כאמור תתקבל מראש... בעניין שטנג, ההחלטה נתקבלה לאחר תיקון מס' 18, אף שהפעולות הפיסיות כבר נעשו בעבר. במובן זה אין מניעה אכן לומר כי ההחלטה כיום, לאחר התיקון, מכשירה את המשך הקיום בעתיד של הבניה...". [השווה גם לא מור בפסק הדין בע"א 93/84 קדמי נ' קוין, פד"י (מ) 724, וכן לדברי א. אייזנשטיין, שם, 229].

ודוק: דברים אלו יפים מקל וחומר, במקרה בו טרם בוצעה הבניה, ובעת הדיון ב פני המפקח מוגשות ההסכמות להרחבה.

14. על כן, גם בנדון דנן, עלינו לבחון האם הוצגו ההסכמות הנדרשות כיום – היינו, **בעת ההכרעה בבקשה למתן צו מניעה קבוע**.

24. אין ספק, כי נכון להיום הוצגו הסכמותיהם של בעלי תת חלקה 1, ה"ה דהן [ר' נספח ב1 לתשובת המשיבים לבקשה לצו מניעה (להלן: "מוצג ב' 1"), וכן נספח ב' לתצהיר הנתבעים]; הוצגה הסכמתו של בעל תת חלקה 3, ה"ה רוטנברג [ר' נספח ב' לתצהיר הנתבעים]; הוצגה הסכמתה של בעלת תת חלקה 4, ה"ה ויזל אסתר [ר' נספח ב' לתצהיר הנתבעים].

אשר לתת חלקה 5 הרשומה על שם בני הזוג הברפלד, בסופו של יום, אין ספק כי הוצגה חתימתו של מר הברפלד וכן חתימת כל יורשי המנוח ה [נר נספחים א- ב לתצהיר הנתבעים].

מר לוין, בעל הזכויות בתת חלקה 6 הינו ממבקשי ההיתר וחתימתו מתנוססת אף היא על נספח ב' לתצהיר הנתבעים.

בעל הזכויות בתת חלקה 7, ה"ה קוזליק משה, כמו גם בעלת הזכויות בתת חלקה 10 ה"ה מלוביצקי אלישבע, חתמו גם הם על הסכמה לבניה [ר' נספח ב' לתצהיר הנתבעים].

אשר לתת חלקה 9, הרשומה בבעלות אלנקרי יוסף ומרים, הלא הם הנתבעים 2-3, טענו הנתבעים, כי רק מר אלנקרי חתם על הסכמתו לבניה, ואילו לא הוכח שהגב' אלנקרי מסכימה לבניה. יש לדחות הטענה מכל וכל. היתר הבניה הנתקף בתובענה זו נוגע לדירתם של ה"ה אלנקרי, וברור כי הם נמנים על מבקשי הבניה. לא זו אף זו, אם היה ספק למאן דהוא בדבר רצונה של הגב' אלנקרי [ולא היה ספק במקרה דנן], הרי שכתבי הטענות שהוגשו בשמה של הגב' אלנקרי [הנתבעת מס' 2] קרי, כתב התשובה לבקשה לסעד זמני,



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- הבקשה לצמצום צו המניעה , וכתב ההגנה , הבהירו את עמדתה הברורה ביחס לבניה המבוקשת. בצדק נטען על ידי הנתבעים, כי טענה זו טוב היתה לה שלא תטען כלל.
34. נמצא אפוא, כי אין ספק, כי נכון להיום, בידי הנתבעים הסכמותיהם של בעלי הזכויות ב- 8 דירות מתוך 11 דירות.
44. מכאן, יש לפנות ל מחלוקת הצדדים ב עניין תת חלקה מס' 8, הרשומה כיום בבעלות התובעים. מובן, כי לו יימצא כי יש לראות את בעלי דירה 8 כמי שנתנו הסכמתם לבניה, הרי שבידי הנתבעים רוב של 9 מתוך 11 דירות, קרי למעלה מ- 75%, וממילא מתייתרות רוב השאלות הנוספות שבמחלוקת.
54. כמובא לעיל, התובעים רכשו את דירה מס' 8 בשנת 2005, מאת הגב' נאווה מונסה, אחיה, ואחיותיה, אשר הזכויות בדירה הועברו להם מהוריהם, בירושה ובמכר ללא תמורה. כפי שהוכח הן ממוצג ב/1 והן מעדותה של הגב' מונסה [ר' שורות 18-19 בעמוד 7 לפרוטוקול], היא חתמה על הסכמתה לבניה המבוקשת. אין חולק כי יתר בעלי הזכויות בדירה 8 לא חתמו על כתב ההסכמה, אך נטען על ידי הנתבעים, כי גב' מונסה חתמה בשם כל בעלי הזכויות בדירה מס' 8 במועד הרלוונטי.
64. להווי ידוע, כי הסכמה להרחבה עשויה להינתן אף בעל פה [ר': ע"א 815/81, **כליפא נ' שאול**, פד"י לו(3), 78]. כמו כן, ניתן אף ליתן הרשאה לשלוח לחתום על הסכמה. יחד עם זאת, במקרה זה, יהא צורך להביא ראיות בדבר ההסכמה או בדבר השליחות הנטענת.
74. והנה, עדותה של הגב' מונסה בעניין זה היתה אמינה ביותר. בעדותה [שם, שורות 21-23] הבהירה הגב' מונסה כי היא חתמה בשם כל בעלי הזכויות במועד הרלוונטי, היינו אחיה ואחיותיה. כך העידה גב' מונסה:
- "היורשים האחרים לא חתמו, כי מי שניהל את ענייני הדירה זאת היתה אני, הם הסמיכו אותי, היה אמון ואני עשיתי הכל. אין לי ייפוי כח לכך".**
- אמנם הגב' מונסה לא דייקה בתאריך כזה או אחר, אך לא היה בכך לערער את עדותה בעניין הרשות לפעול בשם יתר היורשים. אך טבעי הוא כי הגב' מונסה לא תזכור במדויק את המועדים השונים שאינם רלוונטים לגביה, ואין בכך כדי להורות על כי היא אינה מדויקת בעניין ההרשאה שקבלה.
84. זאת ועוד, משעה שהוצג המסמך המעיד על חתימת אחד מבעלי דירה 8 במועד הרלוונטי, ונוכח העובדה כי כבר בתצהירה [סעיף 4 לתצהירה מיום 29.2.12] הבהירה הגב' מונסה, כי היא חתמה בשם יתר היורשים, הנטל להפריך את ההסכמה הועבר לכתפי התובעים. התובעים בחרו שלא לזמן את יתר היורשים, ולפיכך יש לראות זאת דווקא כראיה



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

לחובתם [ר': ע"א 548/78, שרון נ' לוי, פ"ד, ל"ה(1), 736, ע"א 2275/96, לימה נ' רוזנברג, פ"ד מז(2), 605, ע"א 27/91, קבלו נ' שמעון עבודות מתכת, פ"ד מט(1), 450].

94. יש אפוא לקבוע כי בעלי הזכויות בדירה 8, אשר קדמו לתובעים, חתמו על הסכמתם להרחבה המבוקשת.

05. בכך לא תם הדיון ביחס לדירה מס' 8, שכן עדיין יש לבחון האם הסכמתם של בעליה הקודמים של דירה 8 [מונסה ואחיה] מחייבת את התובעים כמי שבאו בנעליהם, אם לאו.

15. אין ספק, כי ככלל, על מנת שהסכמה מסוימת בבית המשותף תהא תקפה כלפי כולי עלמא, יש לרשמה בתקנון הבית המשותף או בספר ההחלטות של הבית המשותף. עם זאת, היעדר הרישום אינו פוגם בתוקפה של ההסכמה לגופה, וצד שידע או שהיה עליו לדעת על ההסכמה, לא יוכל להשתחרר ממנה, מקום בו שינה מקבל ההסכמה את מצבו ופעל על פיה [ר' למשל פסק הדין בע"א (חי') 1020/03 בובליל נ' שטיינר (פורסם באתר נבו); מ. דויטש, קניין, 734]. כך סיכם זאת המלומד אייזנשטיין [א. אייזנשטיין, שם, 228]:

"כאשר ראובן נותן הסכמתו לשמעון להרחיב את דירתו ולימים מוכר ראובן את דירתו ללוי, מבלי להודיע אודות ההסכמה שנתן. האם הסכמת ראובן מחייבת את לוי? כאשר הסכמת ראובן נרשמת יחד עם הסכמת הרוב כהחלטה בספר ההחלטות, הרי היא מחייבת "כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת החלטה ובין שהיה לבעל הדירה אחרי קבלתה" (סעיף 71). יתר על כן, אם החלטת הרוב נרשמה בספר ההחלטות, כי אז מחייבת ההחלטה את לוי גם אם ראובן לא הסכים להרחבה. אם הסכמת ראובן לא נרשמה יחד עם הסכמת הרוב כהחלטה בספר ההחלטות וההסכמה כוללת הוצאת חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירת שמעון, הרי כל עוד ההצמדה לא נרשמה, רואים את ההסכמה כהתחייבות לעשות עסקה במקרקעין. במקרה זה יחול סעיף 9 לחוק שקובע כי זכותו של הראשון, היינו של שמעון, עדיפה על פני זכותו של השני, היינו של לוי, אלא אם כן לוי פעל בתום לב ובתמורה והדירה נרשמה על שמו בעודו תם לב, כלומר, לא ידע ולא יכול היה לדעת על ההסכמה שניתנה לשמעון להרחבת דירתו. יש להניח שאם שמעון החל בעבודות הבניה בפועל, לפני רישום הדירה על שם לוי, תישלל מלוי טענת תום-הלב..."



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

25. בענייננו, לאחר שמיעת עדויות הצדדים ובחינת הראיות שהוצגו בפני, הגעתי לכלל מסקנה כי בעת שרכשו התובעים את דירה מס' 8, הם ידעו, או לכל הפחות, היה עליהם לדעת, כי בעליה הקודמים של דירה מס' 8 [מונסה ויתר בעלי הזכויות כאמור] נתנו הסכמתם להרחבה המבוקשת.

35. ראשית, העיד על כך מר לוברבוים בסעיף 6 לתצהירו כדלקמן: "**הובא לידיעתי לפני אישור התכנית ע"י הדיירים בבית, כי מר כובאני פנה אליהם, בנפרד, לרבות לילדיה של גב' צורי הבעלים הקודם של ה"ה רוטנברג, למר הברפלד, למר לוי אחיה של גב' מונסה ודרש מהם לחזור בהם מהסכמתם ולהצטרף להתנגדותו** ...". מר לוברבוים נחקר על עדותו זו [ר' עמוד 8 לפרוטוקול], וגרסתו כלל לא הופרכה. זאת ועוד, התובעים, למרות שידעו על הצהרת מר לוברבוים בתצהירו כאמור, בחרו שלא לזמן לעדות את מר לוי (אחיה של הגב' מונסה), ולנסות להכחיש טענה זו.

45. **יתרה מכך**: המסקנה כי התובעים ידעו, או, למצער, היו יכולים לדעת על הסכמת גב' מונסה בשם בעלי הזכויות של דירה 8, מתחייבת נוכח בחינת ההליכים וההחלטות שהיו בהליך אישור תכנית 8182. מפרוטוקול הדיון בוועדה המחוזית בעניין תכנית 8182 [פרוטוקול מס' 30/02 מיום 10.10.02] עולה, כי התובעים ובעל דירה נוספת, מר בראון (מי שהיה הבעלים הקודם של המחסן שלימים נרכש על ידי כובאני) התנגדו לתכנית. ברי, כי התובעים, כמי שהיו בלב ליבו של ההליך התכנוני, ואף היו בעלי דירה אחרת בבית המשותף, ידעו היטב מי נתן הסכמתו לתכנית ומי התנגד, וטענת התובעים כיום, כי לא ידעו ולא היו יכולים לדעת מה עמדתם של בעלי דירה מס' 8, בנסיבות המתוארות לעיל, משוללת הגיון לחלוטין. זאת ועוד: מפרוטוקול הדיון הנ"ל עולה, כי בדיון בפני הוועדה המחוזית לא נשמעה מפייהם של התובעים טענה כלשהי בדבר היעדר הרוב הנדרש בחוק. עובדה זו מעידה אף היא על כי התובעים ידעו כבר אז, בשנת 2002, כי קיימת הסכמה של דירה מס' 8. לא למותר להוסיף גם, כי אף אם תתקבל עמדת התובעים שלפיה בעת שרכשו את הזכויות בדירה מס' 8 הם לא בדקו את יחסם של המוכרים [מונסה ואחיה] לתכנית, הרי שהתנהלות כזו, מקום בו התובעים היו בעלי דירה בבית המשותף והיו ערים להליכי התכנון, מהווה עצימת עיניים של ממש.

55. הנה כי כן, אין ספק כי כאשר רכשו התובעים את דירה מס' 8, בשנת 2005, הם ידעו, או לפחות היה עליהם לדעת כי בעליה של דירה מס' 8 במועד הרלוונטי, הסכימו לתכנית.

65. משאלו הם פני הדברים, ולאור העובדה שלפיה הנתבעים המשיכו להתקדם בהליכי התכנון על סמך ההסכמות שהוענקו, ואף הוציאו כספים רבים לשם כך [ר' תצהירו של מר



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

- ליווין שלא נסתר בעניין זה כלל [, הרי שבכל הנוגע לדירה מס ' 8 , כבולים התובעים להסכמת קודמיהם.
75. הנה כי כן, בסופו של יום, אכן הוכח כי בידי הנתבעים הסכמותיהם של 9 דירות מתוך 11 דירות, ומכאן שבאמתחתם הרוב הנדרש לביצוע ההרחבה.
85. כאמור, התובעים טענו גם, כי אף אם היה לנתבעים הרוב הדרוש אין לאשר בקשתם מאחר שהם פוגעים בזכויות הבניה היחסיות השייכות לתובעים.² כפי שהובא לעיל, טענו התובעים כי הנתבעים מנצלים זכויות בניה בשיעור של 255 מ"ר, מתוך 283 מ"ר שאושרו בסך הכל, ואף הפנו לעדותו של מר לוי (בעמוד 9 שורות 30-31 לפרוטוקול), שהתייחס לניצל זכויות בשיעור של 214 מ"ר. לעומת זאת, במסגרת הדיון בבקשה למתן סעד זמני, טענו הנתבעים כי סך השטחים העיקריים המנוצלים על ידם הינו 182.6 מ"ר, כך שנותרים 100.4 מ"ר לניצול יתר בעלי הדירות.
95. לאחר שבחנתי את הראיות שבפני הגעתי למסקנה כי גם בעניין זה הצדק עם הנתבעים. אין חולק כי תכנית 8182 מוסיפה זכויות לשטחים עיקריים בשיעור של 283 מ"ר [ר' סיכומי התובעים, סיכומי הנתבעים, וכן סעיף 9 לתקנון תכנית 8182]. במקביל, מהיתר הבניה [נספח ח' לתגובת המשיבים לצו המניעה], עולה מפורשות, כי במסגרת ההרחבה המבוקשת מנוצלים אחוזי בניה ביעוד לשטח עיקרי בשיעור של 182.91 מ"ר [ר' טבלת השטחים בנספח ח']. מכאן המסקנה, כי אכן נותרים זכויות בניה לשטח עיקרי בשיעור של כ- 101 מ"ר.
06. והנה, אף לו היו התובעים זכאים לזכויות הבניה בגין שלוש הדירות שכיום בבעלותם, הרי שלכל היותר הם היו זכאים, ל - 67.5 מ"ר $(283 \times 532 / (57 + 57 + 13))$. מאחר שנותרו, כאמור, זכויות בניה לשטח עיקרי בסך של 101 מ"ר, מובן כי לא נלקחו מהתובעים זכויות בניה יחסיות.

² ואכן, סעיף 71ב(ב) לחוק קובע כי, "לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה". ר' לעניין זה הבהרתו של המלומד אייזנשטיין [שם, 234] שהסביר כי: "רוב בעלי הדירות אינם רשאים להחליט על הרחבת דירת א' תוך קיפוח בעל דירה ב'. לדוגמא, שני בעלי דירות עליונות מבקשי להרחיב את דירותיהם ולבנות על גג הבית. בהנחה ששתי הדירות שוות בשטחן ובחלקיהן ברכוש המשותף הצמודים להן, אין הרוב רשאי לאשר לא' להרחיב את דירתו על 75% משטח הגג, שכן בכך הוא שולל מ- ב' את זכותו להרחיב את דירתו גם על 50% משטח הגג. לעניין זה מתייחס סעיף 71ב(ב)...הרוב רשאי אמנם להחליט לאשר הרחבה ל- א' ולא לאשר הרחבה ל- ב', אולם הרוב אינו רשאי לאשר הרחבה ל- א' על חשבון ב' תוך קיפוחו...".



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

16. דינה של טענה זו להידחות אפוא.
26. בכל הנוגע לטענת התובעים בדבר פגיעה בתשתיות הבית המשותף – הרי שהנתבעים כלל לא הרימו את הנטל להוכיח כי תיגרם להם פגיעה כלשהי, וודאי לא פגיעה המצדיקה דחיית בקשת הנתבעים להרחבת דירתם. בהקשר זה לא למותר להפנות גם לקביעותיה של ועדת הערר המחוזית לתו"ב [נספח ז' לבקשה למתן צו מניעה זמני] וכן להחלטת הוועדה המחוזית עת היא החליטה לאשר את תכנית 8182 [נספח ה' לבקשה לסעד זמני], שדחו טענות אלו של התובעים. דינה של טענה זו להידחות גם היא.

ה. סוף דבר:

36. לאור כל המוסבר הרי שלנתבעים הרוב הדרוש בחוק להרחבת דירותיהם בהתאם להיתר הבניה. לפיכך, ובהתחשב ב עובדה שלא נמצא ממש בטענת התובעים ביחס לפגיעה בזכויותיהם, הרי שהנתבעים רשאים להרחיב את דירותיהם בהתאם להיתר הבניה.
46. התביעה נדחת. צו המניעה הזמני בטל.
56. התובעים ישלמו לנתבעים הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 7,500 ₪.
66. לא אוכל לסיים את פסק הדין מבלי להתייחס לניסיונות הנתבעים לבוא לקראת התובעים בהצעות לפשרה, שחלקן היו נדיבות עד מאוד. חבל שהתובעים שללו ניסיונות אלו, ויש לקוות כי למרות שהתביעה נגד הנתבעים נדחתה, שערי פשרה לא יינעלו, ובמיוחד בימי הסליחות והרחמים ישכילו הצדדים להגיע ביניהם לעמק השווה על מנת שיצליחו לדור יחדיו באחוזה בבית המשותף.

ניתן היום י"ט אלול תשע"ב, 06 ספטמבר 2012, בהעדר הצדדים, וישלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין